

1501041-45.2022.8.26.0619

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LEOPOLDO VILELA DE ANDRADE DA SILVA COSTA

Comarca: Taquaritinga

Foro: Foro de Taquaritinga

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 26/10/2022

... Criminal, Rel. Des. Roberto Midolla, j. 28.06.12.

Além disto, o tráfico suporta o vício. E para o viciado obter recursos para obter a droga muitas vezes comete outros delitos, em especial, delitos patrimoniais. Assim, indiretamente, o tráfico fomenta toda uma gama de criminalidade. Diversos crimes orbitam o tráfico de entorpecentes.

Na atual sociedade nesta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taquaritinga

Foro de Taquaritinga

1ª Vara

Rua Duque de Caxias, 267, ., Centro - CEP 15900-000, Fone: (16) 3252-5533,

Taquaritinga-SP - E-mail: taquaritinga1@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1501041-45.2022.8.26.0619

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ABDIEL RICHELME RAMOS DA SILVA ALVES

Data da Audiência:

26/10/2022

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Réu Preso

Aos 26 de outubro de 2022, às 16:00h, na sala virtual de audiências do aplicativo Microsoft Teams da 1ª Vara, da Comarca de Taquaritinga, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. LEOPOLDO VILELA DE ANDRADE DA SILVA COSTA, comigo Escrevente ao final nomeada, foi aberta Audiência de Instrução, Interrogatório, Debates e Julgamento, com supedâneo no Provimento CSM nº 2651/2022. Foi feito uso da ferramenta Microsoft Teams, estendida inclusive para as deliberações e providências surgidas por ocasião dos desdobramentos da instrução, no que diz respeito ao cumprimento de prazos e tomada de iniciativas processuais. Todos os participantes desta audiência o fizeram em tempo real, pois é assim que funciona a própria plataforma digital. Pela Defesa foi dispensada a entrevista com o acusado, por meio de reunião paralela pelo Teams. Instalou-se formalmente a audiência. Verificou-se a presença do DD. Representante do Ministério Público o DR. PAULO AUGUSTO RADUNZ JUNIOR. Presente o réu ABDIEL RICHELME RAMOS DA SILVA ALVES e seu Defensor o DR. AGUINALDO LUIZ COUTO-OAB 461904/SP. Presentes as testemunhas ADRIANO MARQUES DA SILVA e ANA CLARA ORLANDINI, acompanhada de sua tia. Iniciados os trabalhos, foi colhido o depoimento da testemunha ADRIANO

MARQUES DA SILVA e na sequência foi colhido o depoimento da menor ANA CLARA ORLANDINI, que alegando temor foi ouvida na ausência do réu, nos termos do artigo 217 do CPP. Em seguida, foi colhido o interrogatório do réu, pelo sistema audiovisual. Os depoimentos das testemunhas foram tomados sucessiva e individualmente na reunião de videoconferência, em preservação à incomunicabilidade prevista no art. 210, do Código de Processo Penal. O interrogatório do acusado está em conformidade com o artigo 405, § 1º, do CPP. A gravação da audiência ficará armazenada no sistema informatizado SAJ-PG5. A seguir, disseram as partes que não têm diligências a requerer. Então não havendo outras provas a serem produzidas, nem requerimento de diligências pelas partes (artigo 402 do Código de Processo Penal), o MM. Juiz encerrou a instrução. Na sequência, foi dada a palavra ao DD. Promotor de Justiça e à Defesa, para alegações finais orais, as quais foram colhidas pelo sistema audiovisual. Pelo MM. Juiz foi proferida a sentença:

"Vistos.

ABDIEL RICHELME RAMOS DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, por incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 13 de julho de 2022, por volta das 15:08 horas, na Rua João Fontanelli, nº 44, Jardim Portugal, na cidade de Fernando Prestes, comarca de Taquaritinga, trazia consigo, guardava e tinha em depósito 52 (cinquenta e duas) pedras de "crack" e 03 (três) porções de "maconha", conforme auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 23/24) e laudos periciais (fls. 116/118 e 122/123), sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Auto de prisão em flagrante (fls. 01).

Em audiência de custódia, foi convertida em preventiva a prisão em flagrante do acusado (fls. 70/72).

Indeferido o pedido de liberdade provisória formulado pela Defesa (fls. 89/90).

O réu foi notificado (fls. 164) e apresentou defesa prévia (fls. 169/171).

A denúncia foi recebida em 22 de agosto de 2022 (fls. 172/174) e, designada audiência de instrução, debates e julgamento, pelo sistema de videoconferência, de forma híbrida, foram ouvidas quatro testemunhas, sendo uma arrolada pela acusação, uma em comum, duas arroladas pela defesa e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia.

A Defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição do réu por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Na hipótese de condenação, requereu a aplicação da pena no patamar mínimo.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

O pedido é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletins de ocorrência (fls. 12/14), auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), fotografias (fls. 18/22), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 23/24), laudos periciais (fls. 116/118, 119/121), e pela prova oral produzida nos autos.

A autoria também é indubitosa.

Em sede policial, o acusado negou que a droga fosse sua, alegando que estaria no local dos fatos porque é usuário de crack e teria ido comprar de um outro "moleque" que estava escondendo a droga, mas que não era ele. Afirmou que o dinheiro que estava consigo havia adquirido trabalhando e que o rasgou porque teria ficado revoltado ao ver que seria preso.

Em juízo, o réu alegou que tem 20 anos e estava desempregado. Anotou que responde a outro processo pelo crime de tráfico. Alegou que umas três semanas antes dos fatos começou a trabalhar com "Cavalinho". Afirmou que recebeu R\$ 130,00 pelo serviço. Alegou que ficou de domingo a quarta usando drogas pela rua. Afirmou que conversou

com os pais e decidiu procurar ajuda. Afirmou que passou pela pracinha e comprou duas pedras de crack de "Luan". Disse que em seguida passou com a psicóloga e pediu uma vaga para tratamento. Afirmou que no retorno, usou a droga e passou novamente na pracinha, para comprar mais. Disse que localizou a sacolinha. Afirmou que jogou a sacolinha em uma casa e pulou dentro de outra casa. Disse que o celular quebrou ao pular na casa. Afirmou que não rasgou o dinheiro, mas estava amarrotado. Alegou que a sacola com as drogas era de "Luan". Afirmou que quando menor ficou internado na Fundação Casa algumas vezes.

Todavia, a versão dada pelo réu se apresenta isolada nos autos, não sendo hábil a contrariar o conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório.

A testemunha de acusação Jhoni Piotto, policial militar, declarou que na data dos fatos, durante patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, deparou-se com o réu Abdiel, conhecido dos meios policiais. Disse que ao perceber a presença da viatura, o acusado saiu correndo e jogou uma sacolinha dentro do quintal de uma casa, que fica ao lado da praça. Relatou que acompanharam o réu e viram-no pular dentro do quintal da casa vizinha, de nº 54. Afirmou que a pessoa residente no nº 44 os chamou, dizendo que sua cachorrinha estava cheirando um saco que alguém havia acabado de jogar em seu quintal e os entregou. Na sequência, a moradora da residência de número 54 informou que um indivíduo havia ingressado em seu imóvel e autorizou que eles adentrassem. Afirmou que localizaram Abdiel escondido em um quartinho aos fundos, atrás de um colchão. Mencionou que, ao encontrá-lo, ele estava quebrando o celular. Procedida revista pessoal, foram encontradas em seu bolso da frente notas de R\$ 10,00, rasgadas, e no de trás, uma nota de R\$ 5,00. Pelos pedaços de notas que apreenderam em poder do acusado, verificou que seriam quatro notas de R\$10,00. Relatou que dentro da sacola arremessada pelo acusado havia 52 pedras de "crack", devidamente embaladas e prontas para venda e 03 porções de "cocaína", também embaladas. Afirmou que diante dos fatos e suas circunstâncias, foi dada voz de prisão ao acusado, que foi conduzido à UBS local e a seguir apresentado à Delegacia de Polícia, onde foi preso em flagrante. Esclareceu que ao avistar o réu ele estava sozinho, na pracinha, mexendo em um "matinho", tendo saído correndo ao avistar a viatura. Esclareceu que estava a cerca de 20 ou 30 metros do acusado no momento em que o viu arremessando a sacolinha no quintal da residência e que ao avistá-lo na pracinha, a viatura estava a cerca de 50 metros. Que no dia do fato o acusado comentou que iria se internar. Disse que Ana Clara entregou as drogas nas mãos da corporação.

A testemunha de defesa Daniela Aparecida Alves da Cunha, psicóloga, declarou que o acusado foi preso na sexta-feira e que, na quinta-feira de manhã ele havia a procurado, buscando uma internação para tratamento da sua dependência, de forma voluntária. Anotou que não sabe o quadro dele, pois ele não fazia acompanhamento com ela. Esclareceu que apenas orientou o réu e informou que a vaga seria disponibilizada na segunda-feira, na cidade de Catanduva, tendo ele concordado. Disse que foi a primeira vez que o réu buscou por internação e que sentiu que ele, de fato, queria ao menos tentar. Mencionou que tinha entrado em contato com os policiais para saber se ele estaria tentando "fugir" de alguma coisa e que foi informada de que não tinha nenhuma ordem de prisão em desfavor dele até então. Afirmou que após a prisão, procurou os policiais para saber se o acusado seria solto, pois nesse caso seguraria a vaga, tendo os policiais dito que poderia dispensar a vaga, pois o réu seguiria preso. Esclareceu que não foi feita anamnese e que foi apenas uma conversa e não uma consulta. A anamnese, a consulta com o médico e os demais trâmites seriam realizados na sexta-feira.

A testemunha em comum Adriano Marques da Silva, policial militar, declarou que durante patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, em companhia do Cabo Jhoni, avistaram Abdiel, conhecido dos meios policiais por envolvimento com o tráfico de drogas, mexendo em um mato, na pracinha. Ao avistar a viatura policial, o acusado tentou empreender fuga, tendo saído correndo e jogado uma sacolinha dentro do quintal de uma residência, localizada à Rua João Fontanelle, nº 44, que fica ao lado da referida pracinha. Disse que viram o acusado pulando para dentro do quintal de uma residência vizinha, de nº 54. Afirmou que a residente da casa de numeral n. 44, Ana Clara, chamou os policiais e disse que sua cachorrinha estava cheirando uma

sacolinha que uma pessoa havia acabado de jogar. Contou que pegaram tal sacola e que em seu interior havia 52 pedrinhas de "crack", devidamente embaladas e prontas para venda, e três porções de "cocaína", também embaladas. No momento em que abordaram o acusado no quintal em que ele havia pulado para escapar da abordagem, ele estava quebrando o celular que trazia consigo. Abordado e procedida a revista pessoal, em seu bolso dianteiro foram encontradas notas de R\$ 10,00, rasgadas. Pelos pedaços de notas que viu, acredita que se tratavam de quatro notas de R\$10,00. Indagado, o réu negou que a droga fosse sua, alegando que estava no local para comprar drogas para seu consumo e que teria saído correndo do local por medo da polícia. Alegou que o réu é bem conhecido dos meios policiais, já tendo sido apreendido mais de quatro a cinco vezes quando era adolescente. Alegou que o réu estava sozinho no local dos fatos, não havendo nenhuma outra pessoa. Anotou que viu o réu andando com a sacola dispensada. Esclareceu que nunca viu o réu trabalhando. Informou que tinha conhecimento do encaminhamento do réu para tratamento. Contou que a menor Ana Clara estava sozinha, lavando a calçada. Afirmou que a menor estava acompanhada do genitor.

A testemunha de defesa Ana Clara declarou que foi sua cachorra que localizou a "sacolinha". Alegou que não viu quem jogou. Contou que sua cachorra pegou a sacola e observou que havia uma substância dentro, tendo entregue aos policiais. Afirmou que estava na garagem e não viu quem arremessou a sacola. Disse que viu uma vizinha dizendo que um homem havia invadido a casa dela, tendo ficado assustada. Disse que foi até a frente de sua casa pra ver o que estava ocorrendo, quando viu os policiais.

O conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e, portanto, apta para ensejar a condenação do acusado.

Os depoimentos dos policiais foram seguros ao imputar ao réu a posse 52 pedras de "crack" e 03 papелotes de "cocaína", que estavam acondicionados em uma sacola que ele levava consigo e a qual ele se desfez ao ver a viatura policial.

Não há que se falar em valor reduzido dos depoimentos dos policiais. Nada há nos autos a apontar que tivessem algum interesse em incriminá-lo falsamente e, assim o fosse, se houvesse desconsideração da palavra dos policiais em todos os processos não haveria justiça, mas sim impunidade.

Veja-se, à propósito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos". (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

"Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (STJ - HC n. 449.657/SP, Min FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe de 14/8/2018).

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - RECURSO MINISTERIAL VISANDO À CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DA DENÚNCIA - PROVIMENTO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS SEGUROS E COERENTES COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. Tendo os policiais apresentado depoimentos seguros e coerentes com os demais elementos dos autos e inexistindo evidência de que aqueles tivessem qualquer motivo para incriminar o acusado falsamente, impõem-se a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes. Recurso provido, para condenar o apelado pelo delito do artigo 33, "caput" e §4º, da Lei nº 11.343/06. (TJSP. Apelação Criminal 1500057-52.2020.8.26.0580; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Assis - 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a

Mulher; Data do Julgamento: 25/03/2021; Data de Registro: 26/03/2021) - grifei. Tráfico de entorpecentes - Agente que traz consigo 13 porções de cocaína (2,66 gramas) - Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório - Validade. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

(TJSP. Apelação Criminal 0000581-23.2016.8.26.0594; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Duartina - Vara Única; Data do Julgamento: 01/04/2020; Data de Registro: 01/04/2020) - grifei.

Narraram com detalhes a dinâmica dos fatos. Não há contradição, os depoimentos são uníssonos.

Em verdade, seria um contrassenso exigir o exercício da ação inibidora da polícia para combater as infrações penais e, quando ela tem sucesso nessa empreitada, dizer que seu depoimento é inválido, suspeito, mentiroso, parcial, por que não dizer, criminoso.

Note-se que, ao avistar a viatura policial, o acusado tentou empreender fuga, arremessou no quintal de uma residência a sacola em que carregava as drogas e ainda, quebrou o aparelho celular que levava consigo, condutas incompatíveis com as de quem nada fazia de ilícito no local, ponto de venda de drogas.

Reforce-se que, além das drogas, foram encontradas em poder do réu cédulas de R\$ 10,00, rasgadas, e uma nota de R\$ 5,00, sem que este tenha comprovado o exercício de atividade lícita. Calha mencionar que, embora tenha alegado que obteve o dinheiro trabalhando, durante sua qualificação, o réu se autodeclarou desempregado (fls. 30).

Nesse contexto, as circunstâncias, a quantidade de drogas apreendidas (52 pedras de crack e 03 papелotes de cocaína - cf. fl. 16/17) e a forma como estavam embaladas autoriza a considerar que as substâncias entorpecentes eram destinadas ao consumo de terceiros, sendo tal preceito expresso na Lei nº 11.343/06.

Cumprе anotar, que em razão do crime de tráfico de drogas constituir atividade clandestina, não é necessário, para a sua caracterização, o flagrante da comercialização das substâncias ilícitas para que se conclua pela autoria do crime em tela, sendo suficiente para tanto a análise das circunstâncias e indícios que conduzem a incriminação, todos a respaldar a convicção pela autoria do acusado no crime de tráfico de drogas.

À propósito, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 33, CAPUT, E § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA. 1. Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. 2. O tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não faz nenhuma exigência no sentido de que, para a caracterização do crime de tráfico de drogas, seja necessária a demonstração de dolo específico, notadamente quanto ao fim de comercialização do entorpecente. 3. Recurso especial provido, para cassar o acórdão recorrido e, conseqüentemente, restabelecer a sentença condenatória. (STJ - REsp 1361484/MG Rel. Min. Rogério Schietti Cruz Sexta Turma j. 10/06/2014).

No mesmo sentido:

Tráfico de Entorpecentes - Art. 33, Lei 11.343/06. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Prova da finalidade de entrega a terceiros, advinda da forma de embalagem e da quantidade de droga. Pena base reduzida.

Substituição da pena. Incabível - Requisitos dos benefícios não foram satisfeitos. Regime mantido. Recurso parcialmente provido. (TJSP. Apelação Criminal 0016290-94.2017.8.26.0196; Relator (a): Freitas Filho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franca - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/06/2019; Data de Registro: 13/06/2019) - grifei.

Diante desse cenário, não há como recepcionar a alegação de insuficiência de provas em relação ao crime imputado ao acusado. Isso porque os relatos apresentados pelas testemunhas constituem provas firmes e robustas, mais que suficientes a reforçar a convicção de que o réu realmente trazia consigo drogas, no local em que foi detido em flagrante, na ocasião. Portanto, nada há nos autos que possa macular a acusação, mostrando-se a prova colhida absolutamente suficiente para a condenação.

Ademais, é cediço que a condição de usuário não afasta, necessariamente, a de traficante, pois, na maioria das vezes, os usuários se valem do comércio ilícito de entorpecentes para sustentar o próprio vício, de modo que uma conduta não exclui a outra.

O uso de entorpecente é a porta de entrada para a atividade de traficância. Assim, incabível o pleito desclassificatório, pois as drogas que possuía não eram destinadas ao uso. Neste sentido: “A condenação penal pelo crime de tráfico não é vedada pelo fato de ser também o agente um usuário da droga. Não descaracteriza o delito de tráfico de substância entorpecente o fato de a Polícia haver apreendido pequena quantidade do tóxico em poder do réu” (STF 1ª T. HC n. 74.420-6/RJ Rel. Min. Celso de Mello DJU de 19.12.96, p. 51.768).

Portanto, nada há nos autos que possa macular a acusação, mostrando-se a prova colhida absolutamente suficiente para a condenação.

Nesta senda, a prova coligida é segura e eficaz para justificar a materialidade e autoria do delito, bem como o dolo e culpabilidade do agente, sendo a condenação de rigor.

Passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, fixo a pena base em 1/6 acima do mínimo legal, diante da diversidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, já que a “cocaína” possui efeitos devastadores.

Com efeito, quando o legislador determinou, no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, que o juiz, na fixação das penas, considere com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância, quis dizer que, quem trafica “cocaína” deve ser punido mais severamente do que quem trafica outras drogas menos vulnerantes, como, por exemplo, apenas a maconha.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Absolvição – Improcedência – Materialidade e autoria demonstradas – Acusado surpreendido com 14 pinos de cocaína, com peso líquido total de 19,41g – Firmes e coerentes os depoimentos dos policiais militares – Intuito mercantil demonstrado – Condenação de rigor – Dosimetria – Pena-base fixada 1/6 acima do mínimo legal – Natureza do entorpecente apreendido que justifica o aumento – Artigo 42 da Lei nº 11.343/06 – Reprimenda agravada em 1/6 pela reincidência – Redutor do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 e Substituição penal – Inaplicabilidade – Requisitos legais não preenchidos – Regime inicial fechado mantido, porque adequado à gravidade concreta da conduta praticada – Recurso não provido (TJSP. Apelação nº 0001327-39.2018.8.26.0619. Relator(a): Salles Abreu. Comarca: Taquaritinga. Órgão julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 17/12/2018. Data de publicação: 15/01/2019). Negritei.

Ainda, a esse respeito:

“O juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006”. (AgRg no HC 631774 / SE AGRADO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2020/0327617-0. Relator(a) Ministro FELIX FISCHER (1109) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 23/03/2021 Data da Publicação/Fonte DJe 29/03/2021) – grifei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.

NATUREZA NOCIVA DAS DROGAS APREENDIDAS (CRACK E COCAÍNA). ART. 42 DA LEI N.

11.343/06. AGRADO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos crimes de tráfico de drogas, o Juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal - CP, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 2. No caso, a natureza das drogas apreendidas (crack e cocaína) justifica a majoração da pena-base, em relação à

Debora, bem ainda a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, em seu patamar mínimo, para o réu Geraldo. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. Processo" (AgRg no HC 476995 / SC AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2018/0289466-0 Relator(a) Ministro JOEL ILAN PACIORNIK (1183) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 23/04/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 03/05/2019) - grifei.

"A alta nocividade da cocaína está a exigir especial rigor no combate a seu tráfico, impondo-se, em consequência, a aplicação aos traficantes de reprimendas penais de severidade correspondente ao elevado risco que a nefanda mercancia acarreta à saúde pública" (TJRS - AC 687055624 - Rel. Des. Jorge Alberto de Moraes Lacerda, v. un. 29.12.1987).

Pena base, portanto, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na segunda fase, em que pese a atenuante da menoridade relativa, já que o réu era menor de 21 anos na data dos fatos, verifico que o acusado é duplamente reincidente, sendo uma delas de forma específica, conforme se verifica da certidão acostada às fls. 201/204 dos autos (Proc. nº 1500083-03.2020.8.26.0531, 1500110-76.2021.8.26.0619), de modo que deverá ser a pena majorada em 1/6.

Nesta esteira, de acordo com a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça tratando-se de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a menoridade relativa, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A MENORIDADE RELATIVA E A AGRAVANTE DA RECIDIVA. DUPLA REINCIDÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. No julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". 3. Hipótese em que tratando-se de réu multirreincidente, é válida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal sob a atenuante da menoridade relativa, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 4. Writ não conhecido. (HC n. 556.397/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 26/6/2020.)

Ademais, deixo de considerar a condenação nos autos n. 1500582-14.2020.8.26.0619, para o recrudesimento da pena, uma vez que, na esteira do entendimento dos Tribunais Superiores, a condenação nas penas do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, não pode ser valorada como maus antecedentes ou reincidência.

Nesse sentido:

"[...] 8. Ademais, este Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que se revela desproporcional o reconhecimento da reincidência em virtude de anterior condenação pelo delito previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006. Nesse contexto, se os efeitos da reincidência decorrentes de anterior condenação por posse de drogas para uso próprio devem ser afastados, com mais razão ainda os relativos aos maus antecedentes, à personalidade do agente e à conduta social, como na espécie. Precedentes. [...]" (AgRg no AREsp 1679045/AC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 02/06/2020);

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA ASSENTADA EM ANTERIOR REGISTRO DE INCIDÊNCIA AO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO APTA A JUSTIFICAR A MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA. DESPROPORCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Conquanto não ultimado o

juízo do RE 635.659 (Relator Ministro Gilmar Mendes), que discute a constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006, revela-se desproporcional considerar condenação anterior pela prática de porte de droga para consumo próprio como causa hábil a configurar reincidência e afastar a incidência do redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas. 3. Não se afigura razoável permitir que uma conduta que possui vedação legal quanto à imposição de prisão, a fim de evitar a estigmatização do usuário de drogas, possa dar azo à posterior configuração de reincidência. 4. Além de aparente contrariedade com a própria teleologia da Lei 11.343/2006, no que diz respeito à forma de tratamento que deve ser conferida ao usuário de drogas, deve-se ponderar ainda que a reincidência depende, segundo consolidada jurisprudência desta Corte, da constatação de que houve condenação criminal com trânsito em julgado, o que, em grande parte dos casos de incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006 não ocorre. 5. Cumpre registrar que, nos termos do art. 63 do Código Penal, verifica-se a reincidência “quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior” (grifo nosso). Portanto, o conceito de reincidência reclama a condenação pela prática de um segundo crime após anterior com trânsito em julgado – e não contravenção penal, por exemplo. 6. O art. 28 da Lei 11.343/2006, por não cominar pena de reclusão ou detenção, não configura crime nos termos da definição contida na Lei de Introdução ao Código Penal, e, assim, não tem a condão de gerar reincidência, instituto disciplinado no Código Penal. 7. Agravo regimental desprovido. (RHC 178512 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 17-06-2022 PUBLIC 20-06-2022). Destaquei.

Pena, portanto, em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno a pena 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão definitiva.

A pena pecuniária, utilizando o mesmo critério da privativa de liberdade, é fixada em 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa para o réu, no valor unitário mínimo.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, fixo o fechado, ante a reincidência do réu, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal, e por ser o único compatível com a natureza do delito, equiparado a hediondo.

Não é demais consignar que as nefastas circunstâncias e consequências que o crime de tráfico de entorpecentes causa à sociedade conclamam a fixação do regime mais gravoso, a fim de que se retire o infrator do convívio social, evitando que ele continue a exercer tais atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias. Nesse sentido os recentes julgados do E. Tribunal de Justiça deste Estado: Apelação nº 0001994-15.2011.8.26.0443, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Luis Soares de Mello, j. 26.06.12, e Apelação nº 0011197-28.2006.8.26.0038, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Roberto Midolla, j. 28.06.12.

Além disto, o tráfico suporta o vício. E para o viciado obter recursos para obter a droga muitas vezes comete outros delitos, em especial, delitos patrimoniais. Assim, indiretamente, o tráfico fomenta toda uma gama de criminalidade. Diversos crimes orbitam o tráfico de entorpecentes.

Na atual sociedade nesta Comarca, o tráfico é delito de extrema relevância que demanda combate diuturno das autoridades policiais, judiciárias e do Ministério Público.

Assim, diante das graves consequências sociais, inviável imputar ao traficante regime de pena menos rigoroso do que o fechado.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da presente ação penal que a Justiça Pública move contra ABDIEL RICHELME RAMOS DA SILVA, qualificado nos autos, e o CONDENO à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Deixo de dar aplicação ao disposto no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.736/12 por entendê-lo inconstitucional.

A uma, porque fere o princípio do juiz natural, na medida em que cabe à Vara de Execução Criminal apreciar a progressão de regime prisional, não possuindo esse

juízo, ademais, os elementos necessários para avaliar se o tempo de prisão cumprido até aqui diz respeito a esse ou a outro processo criminal.

A duas, porque viola o princípio da isonomia, na medida em que trata desigualmente réus que praticaram delitos idênticos, quando um deles ficou preso cautelarmente por mais tempo do que o outro.

A três, porque ofende o princípio do livre convencimento motivado do magistrado na sentença, a quem cabe apreciar a justa aplicação da pena.

Pelas circunstâncias do caso concreto e considerando-se que o réu se encontra preso desde o flagrante, além de ser reincidente específico, não se justificaria a soltura após a condenação. Nego-lhe, portanto, o apelo em liberdade. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei nº 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos valores bens apreendidos em poder do réu em favor da União. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Transitada em julgado esta sentença: a) destruam-se as amostras de droga guardadas para contraprova (art. 72 da Lei de Drogas); b) expeça-se/adite-se e encaminhe-se guia de recolhimento definitiva; c) elabore-se cálculo de multa e intime-se o réu para o pagamento; d) oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD); e) oficie-se ao TRE/SP, para os fins do art. 15, III, da CF. f) Diante da pena de multa cumulativamente aplicada, nos termos do disposto no art. 480 das NSCGJ, alterado pelo Provimento CG Nº 05/2022, expeça-se certidão de sentença, abrindo-se vista ao Ministério Público.

Defiro os benefícios da justiça gratuita ao sentenciado, já que a indicação de defensor dativo para patrocinar a defesa sugere a hipossuficiência de recursos financeiros. Anote-se.

Expeça-se todo o necessário, fazendo as comunicações de praxe.

Regularizados os autos e observadas as formalidades legais, arquivem-se."

O dispositivo da r. sentença foi lido pelo magistrado às partes e seu inteiro teor disponibilizado nos autos digitais nesta data. Na sequência, tanto o Defensor quanto o réu interpuseram recurso de apelação, sendo que o Ministério Público concordou com a sentença, não querendo dela recorrer. Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: "Vistos. Dou por certificado nesta data o trânsito em julgado para o Ministério Público. Recebo o recurso interposto, saindo o defensor intimado que o prazo para apresentação das razões recursais se inicia na data de amanhã. Em seguida, abra-se vista ao Ministério Público para contrarrazões de recurso (CPP, art. 600). Após, observadas as cautelas de praxe, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça - Seção Criminal, com as nossas homenagens aos seus ilustres integrantes. Encaminhe-se as gravações da audiência realizada, nos termos do Comunicado Conjunto nº 1350/2020. Expeça-se certidão de honorários, se o caso." Saem os presentes intimados. Publicada em Audiência, nos termos do Comunicado CG Nº 2200/2016. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação de audiovisual em audiência, as ocorrências, manifestações e declarações e depoimentos captados em vídeo, foram disponibilizados no website do Tribunal de Justiça de São Paulo. Servirá o presente termo, por cópia digitada e acompanhado da sentença, devidamente assinados como ofício de recomendação do réu à prisão em que se encontra. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Luana Yuri de Araújo, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA